

1501465-84.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... de fls. 77/79. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que em viatura descaracterizada observavam o movimento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, que fica defronte a uma escola ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501465-84.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/001090

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259438/2021 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 20418667 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 202/21/593 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9, 2259438 - 3ªHOMICÍDIOS-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO JOSÉ NÉRI

Réu Preso

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: AGNALDO JOSÉ NÉRI - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC CRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC LUIS ANTONIO QUEIROZ - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da PC CRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha LUIS ANTONIO QUEIROZ, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha LUIS ANTONIO QUEIROZ, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu AGNALDO JOSÉ NÉRI foi devidamente interrogado. O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "AGNALDO JOSÉ NÉRI, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 86/89. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 108), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 112/116), sendo a denúncia recebida (fls. 117/119). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, fotografias de fls. 10/12 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 77/79. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que em viatura descaracterizada observavam o movimento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, que fica defronte a uma escola pública. Viram o momento em que o acusado serviu uma pessoa em um carro, que o abordou, bem como se dirigir a uma lixeira próxima e ali manipular algo. Relatou que, ato contínuo, o acusado retornou para as proximidades da escola, momento em que realizaram sua abordagem. Afirmou que, ao ser submetido a revista pessoal, localizaram no bolso da bermuda do réu três eppendorfs contendo cocaína. Aduziu que, em seguida, foram até a lixeira e localizaram mais sete eppendorfs contendo cocaína, cujas embalagens eram idênticas aos eppendorfs localizados com o acusado. Afirmou que o local onde o acusado traficava ficava bem defronte a uma escola pública. No exato mesmo sentido foram as palavras do policial civil Luis Antônio Queiroz, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que parou no local para comprar drogas para seu uso, negando ter manipulado a lixeira mencionada na denúncia. Disse que a pessoa de quem comprou a droga atravessou uma ponte existente no local antes da abordagem policial, vindo ele a saber da quantidade apreendida apenas na delegacia. Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que os policiais foram categóricos ao afirmar que viram o acusado mantendo contato com uma pessoa que o abordou, entregar-lhe algo, e manipular algo em uma lixeira, que se constatou tratar-se do restante dos entorpecentes apreendidos, os quais estavam embalados de forma idêntica aos consigo apreendidos. Os policiais afirmaram, ainda, que o local, já conhecido como sendo ponto de tráfico, fica bem defronte uma escola pública. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas,

justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, verifica-se que o réu ostenta condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas (autos nº 3002734-24.2013 - fls. 90). Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Na terceira fase, inaplicável o art. 33, §4º da Lei de Drogas, vez que o acusado ostenta maus antecedentes pelo crime de tráfico, o que demonstra que, de longa data, ele faz desta prática seu meio de vida, contrariando a impulsividade e eventualidade necessárias para a caracterização do "tráfico-privilegiado". Vale citar, a propósito, o mencionado pelo Desembargador Toloza Neto (Apelação nº 0056977-13.2010.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, julgado em 31.01.2012, publicado em 02.02.2012), analisando hipótese de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06: Não resta dúvida, assim, de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houve dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual. Ainda sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de Habeas corpus: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante o paciente seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais levaram a crer que o sentenciado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao cometimento do narcotráfico. 2. Para entender de forma diversa, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 211975 SP 2011/0153576-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2012). Ainda na terceira fase, tendo em vista que o delito de tráfico foi praticado nas dependências de estabelecimento de ensino, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, circunstância essa comprovada tanto pela prova oral quanto pelo croqui acostado as fls 87. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Cristiano, Policial Civil, declarou que estava em uma viatura descaracterizada observando o movimento da "biqueira", que fica próxima a um colégio público. Visualizaram o réu se dirigindo a um veículo logo após mexer em uma lixeira. Diante disso, efetuaram a abordagem e foram até o ponto, logo após o comprador sair com o veículo, e abordaram o acusado. Inicialmente, ele negou o tráfico, porém, nas mãos dele, encontraram 03 porções de entorpecente. Ao mexerem na lixeira onde o réu estava, encontraram outras 07 porções, idênticas àquelas localizadas com o réu. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O local onde o réu estava fica "na porta" da

escola. Não se lembra do nome do estabelecimento. O acusado estava sozinho, porém, próximo a ele, numa esquina, havia outras pessoas. O réu, em interrogatório, declarou que estava no local junto a um grupo de alcoólatras, tomando sol e bebendo cachaça. Foi levar um cadeirante para a casa dele e comprou 03 pinos para seu consumo, sendo abordado logo em seguida. Não mexeu na lixeira onde os demais entorpecentes teriam sido encontrados. O traficante foi embora e o Policial não o abordou. Não conhecia os Policiais que o abordaram. De vez em quando, permanecia no local para beber cachaça. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática do tráfico de drogas. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da suposta "movimentação suspeita" visualizada, não foram apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos, embora os próprios agentes mencionem que outras pessoas se encontravam no local. Além disso, há certa contradição no depoimento dos Policiais, haja vista que, na Delegacia, eles informaram que teriam recebido uma denúncia prévia sobre o tráfico de drogas na região e estavam no local para apurar a veracidade da informação, porém, em Juízo, este dado não foi apresentado. Ressalta-se, ainda, que a maior parte das substâncias não estava sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas

apreendidas. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição do acusado, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes ou presidiários, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato de o denunciado ter sido surpreendido próximo a uma escola (art. 40, III) não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Ademais, ainda que se entenda de forma diversa, cumpre observar que, na época dos fatos, diante da pandemia de COVID-19 existente no País, muitos estabelecimentos de ensino estavam fechados, realizando as atividades educacionais de forma remota. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material;(...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à

evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: "No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida" (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 - grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário na época dos fatos; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

AGNALDO JOSÉ NÉRI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, o dia 22 de setembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Armando Bogus, nº 220, bairro Pompeia, nas imediações da Escola Municipal "Rachel de Queiroz", nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo e tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 10 (dez) eppendorfs de cocaína em pó, pesando cerca de 1,6g (um grama e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis receberam informações dando conta de que um indivíduo de cor branca, trajando blusa de cor verde e tênis de cor vermelha, estaria promovendo o tráfico de drogas na Rua Armando Bogus, próximo a Escola Municipal Rachel de Queiroz. Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os investigadores se deslocaram até o local indicado e, durante breve campanha, visualizaram o acusado, cujas características físicas e de vestimenta coincidiam com as informadas pelo denunciante, manipular algo em uma lixeira e retornar para as imediações do estabelecimento de ensino acima citado. Em razão disso, os policiais procederam à abordagem e apreenderam na posse do réu, especificamente no bolso de sua bermuda, três eppendorfs de cocaína em pó. Ato contínuo, os agentes da lei diligenciaram na lixeira onde o réu estava manipulando algo anteriormente e localizaram outros sete eppendorfs de cocaína, idênticos aos apreendidos na posse dele.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 108) e apresentou defesa preliminar (fls. 112/116), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia, em

26.11.2021 (fls. 117/119),

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelas fotografias de fls. 10/12, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 77/79, que trouxe resultado positivo para cocaína, e pela prova produzida.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que, no local, ficava um grupo de pessoas, alcóolatrás, sendo ele um deles. Atestou que ficava no local tomando sol e bebendo cachaça. Afirmou que, no dia dos fatos, estava alcoolizado, levou um cadeirante até a casa dele, passou no local e comprou três pinos para usar na sua casa. Alegou que, quando estava voltando para sua casa, foi abordado pelos policiais. Disse que trajava calça preta e camisa preta, mais o tênis vermelho, mas sequer passou perto da lixeira. Sustentou que quem lhe vendeu a droga saiu por uma ponte que atravessa um córrego e vai para outro bairro, de modo que acreditava que os policiais não o viram.

A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

O policial civil Christiano relatou que estavam com viatura descaracterizada e, a uma certa distância, observavam movimentação típica de tráfico defronte a uma escola pública. Disse que viram uma transação típica de tráfico, eis que o réu mexeu numa lixeira e foi até um veículo que estava parado no meio da rua. Asseverou que decidiram fazer a abordagem, instante em que o comprador saiu do local. Disse que abordaram o réu, que negou a prática do crime. Porém, na mão dele havia três porções de entorpecente e, na lixeira, que reviraram, encontraram mais sete porções idênticas.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Luís Antônio.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJ TJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem recebido denúncia anônima dando conta da traficância no local e, logo após, terem flagrado o réu no lugar indicado, cujas características físicas e de vestimentas coincidiam com as informadas, praticando atividades típicas de traficância, vindo a apreender três eppendorfs de cocaína em poder dele, e sete eppendorfs da mesma droga, embalados de maneira idêntica às encontradas com o réu, escondidas na lixeira que ele foi visto acessando, conduzem à certeza quanto a autoria.

Prosseguindo, a quantidade e diversidade do entorpecente apreendido e a forma como estavam acondicionados, aliados à existência de denúncia prévia dando conta da traficância e às circunstâncias da apreensão, deixam evidente que a droga se

destinava mesmo ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Outrossim, a causa de aumento prevista no art. 40, III, do Código Penal, restou suficientemente configurada, eis que o crime foi praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Não é demais anotar que, para a incidência da majorante, não é necessário que o agente vise a difusão do entorpecente entre frequentadores da escola, bastando que o delito se pratique em suas proximidades porque o objetivo da lei é impedir, no máximo, a propagação da toxicomania em locais de maior concentração popular.

Nesse sentido, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação nº 0320753-56.2010.8.26.0000, de que foi Relator o E. Desembargador JUVENAL DUARTE: “E não há como desconsiderar que a causa de aumento em exame é de natureza objetiva, irrelevante, portanto, para a sua configuração, indagar se o autor do crime visava comercializar ou fornecer drogas aos frequentadores desses estabelecimentos públicos, pois a lei exige tão somente que o tráfico ocorra nas imediações desses locais, porquanto, é inegável, o fluxo e a concentração de pessoas nesses sítios facilitam a ação de traficantes e a prática ilícita, dificultando a ação policial, evidenciando que o dano à saúde pública se potencializa exponencialmente”.

Pontuo, por fim, que, como amplamente divulgado pela mídia, as escolas públicas e privadas retomaram as aulas presenciais, ainda que não de forma obrigatória, a partir de agosto de 2021, restando plenamente caracterizada a causa de aumento descrita na inicial.

Logo, de rigor a condenação do réu nos termos da denúncia.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (autos 3002734-24.2013 da 1ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 90/91).

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como maus



anteriores, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos maus antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em seu valor mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase de fixação da pena, aplico o aumento de um sexto, com fundamento no art. 40, III, da Lei 11.343/06, resultando seis anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, e seiscentos e oitenta dias-multa, em seu mínimo legal. E não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, eis que ostenta maus antecedentes, decorrentes inclusive de condenação pela prática de crime de tráfico.

Essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. O § 4º do art. 33, tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. O redutor incide na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (cf. Apelação nº 990.09.155655-6, Rel. Des. Luis Antonio Cardoso, j. 29.6.2010).

Na hipótese, os maus antecedentes pela prática de crime da mesma natureza evidenciam que não é traficante meramente ocasional, mas, ao contrário, está envolvido com atividades criminosas.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a

persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu AGNALDO JOSÉ NÉRI, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de seis anos e nove meses e dezoito dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial fechado, vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 07/02/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]